

刑法
No179

H22-12

(配点: 2)

月 日

月 日

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 殺人の故意を有する者と傷害の故意を有する者との間では、共同正犯が成立する余地はない。
2. 刑法第60条にいう「犯罪」には、教唆犯・従犯も含まれるので、共同して教唆・幫助行為に及んだ者には教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。
3. 成人が刑事未成年者に指示して犯罪を行わせた場合、成人と刑事未成年者との間で共同正犯が成立することはなく、成人に間接正犯が成立するにすぎない。
4. 刑法第65条にいう「身分」は、犯人の一身的な継続的属性に限られる。
5. 窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が、財物を強取した後、実行行為を分担しなかった共犯者にその旨話し、同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。この場合、実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。

No179

共 犯

正答率

H22-12

正 解

2

53%

1 誤っている

暴行・傷害を共謀した被告人らのうちの1人が未必の故意をもって殺人罪を犯した事案で、最決昭54.4.13(百選I92事件)は、殺意のなかった被告人らについては、「殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」とする。理由として、判例は、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一である」ということを挙げている。

2 正しい

大判昭10.10.24、最判昭23.10.23。判例は、幫助、教唆の共同正犯の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、幫助や教唆行為の場合も、「2人以上共同して犯罪を実行した」という60条の文言に反しないことを挙げている。

3 誤っている

母親が、生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男に対し強盗の実行を指示命令した事案において、最決平13.10.25(重判平13刑4事件)は、長男には是非弁別能力があり、母親の指示・命令は長男の意思を抑圧するに足りるものではなく、長男は自らの意思によって強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、奪ってきた金品はすべて母親が領得したという事情の下で、母親と長男との間に共同正犯の成立を認めている。判例に賛成する学説は、成人と刑事未成年との間に共同正犯が成立し得る理由として、共同正犯の成立には、有責性の要件は、本来、行為者各個人に向けられた非難可能性の問題であるから、その判断は個別に行われるべきであり、共犯者間で責任が連帯する必要はないことを挙げている。なお、上記判例では、間接正犯の成否が問題となったが、間接正犯の成立を否定している。

4 誤っている

最判昭27.9.19は、身分とは、「男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たる資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するもの」としている。刑法は、行為者の特性によって犯罪の成立及び刑の軽重に影響を与える場合をすべて「身分」としてとらえているからである。

5 誤っている ★

最決昭54.4.13(百選I92事件)は、故意が異なる共犯者間に成立する犯罪について、「構成要件が重なり合う限度で軽い……共同正犯が成立する」としている。そして、軽い窃盗の認識で幫助していたところ、正犯が重い強盗を実行したという事案や、窃盗を教唆したところ、正犯が強盗を実行したという事案で、判例は、いずれも強盗についての責任を問うことはできないとしており(最判昭23.5.1、最判昭25.7.11(百選I91事件))、窃盗と強盗は、窃盗の限度で重なり合いが認められる。窃盗罪の共謀に基づいて、実行行為を分担した者が強盗を行っているところ、実行行為を分担しなかった共犯者には、共謀の限度である窃盗罪の共同正犯が成立する。なお、共犯者が強取の事実を「了承して上記財物をもらい受けた」とあるため、承継的共同正犯の問題のようにも思えるが、承継的共同正犯とは、先行者が特定の犯罪の実行に着手し、まだ実行行為を全部終了しない間に、後行者がその事情を知りながらこれに関与し、先行者と意思を通じて残りの実行行為をみずから単独で、又は先行者と共に行い犯罪を完成することをいうところ、実行行為者が強取した時点で実行行為は終了しているため、承継的共同正犯の成否は問題とならない。